

1500139-92.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 4ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... ser corriqueira as denúncias de tráfico nos predinhos localizado no bairro, foi efetuado um patrulhamento no local. Ao adentrarem no estacionamento dos predinhos, local que é frequente o tráfico de drogas, avistaram o indiciado e o adolescente. Assim que o indiciado e o adolescente avistaram a viatura se evadiram, sentido linha férrea. Foi efetuado o acompanhamento dos dois. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

4ª Vara Judicial

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-017, Fone: (16)3252 5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL (TELEAUDIÊNCIA)

Processo Digital nº:

1500139-92.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN GABRIEL DE SOUZA DE PAULA

Data da Audiência:

01/09/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 01/09/2022, às 16:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 4ª Vara Judicial, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Matheus de Souza Parducci Camargo, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG de nºs 250/2020 e 284/2020, todos deste Eg. TJSP; Recomendação CNJ 62/2020; bem como Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo). Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, sob a concordância de todos, anuência esta estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Instalou-se formalmente a telaudiência. Verificou-se a presença virtual do DD. Representante do Ministério Público, Dr. ILO

WILSON MARINHO GONÇALVES JUNIOR e do Defensor Nomeado, Dr. ROBERTO YOSHIKAZU OGASAWARA, OAB/SP 145.218. O réu JHONATAN GABRIEL DE SOUZA DE PAULA foi declarado revel (fls. 224). Presente, ainda, virtualmente, a testemunha comum ARMANDO FAGNER ARAUJO. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a colher o depoimento da testemunha comum acima nominada. O depoimento da testemunha foi tomado sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. A mídia digital ficará mantida em computador deste Juízo, em pasta apropriada para armazenamento e compartilhamento. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que não havendo mais provas a produzir, dava por encerrada a instrução passando aos debates orais. Dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça para as alegações finais, pelo mesmo foi dito: " MM Juiz, O(s) réu(s), em epígrafe, foi (ram) denunciado(ram) e está sendo processado(s) como incurso(s) no(s) art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, tudo nos termos do narrado na exordial acusatória. O(s) acusado(s) foi(ram) notificado(s) e citado(s) e apresentou(ram) resposta à acusação, com posterior recebimento da denúncia. Nesta oportunidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedido ao(s) interrogatório(s). Encerrada a persecutio criminis in judicio o Ilustre Magistrado determinou que as partes apresentassem alegações finais neste momento. É o sucinto relatório. Não há preliminares ou potenciais causas de nulidade acerca da tramitação do feito, sendo certo que a relação jurídica processual, desenvolveu-se de maneira escorreita, razão pela qual adentro ao mérito. Impõe-se a condenação dos(as) acusados(as). A materialidade dos crimes está positivada pelo laudo toxicológico definitivo (fls.81/83). A autoria do(s) crime(s) descrito(s) na exordial é inquestionável. O réu ao ser interrogado na DEPOL às fls. 10 preferiu ficar em silêncio. Em juízo, não compareceu sendo decretada a sua revelia. O policial militar Armando Fagner, estavam efetuando patrulhamento pela vila São Sebastião. Por ser corriqueira as denúncias de tráfico nos predinhos localizado no bairro, foi efetuado um patrulhamento no local. Ao adentrarem no estacionamento dos predinhos, local que é frequente o tráfico de drogas, avistaram o indiciado e o adolescente. Assim que o indiciado e o adolescente avistaram a viatura se evadiram, sentido linha férrea. Foi efetuado o acompanhamento dos dois. Durante a fuga o indiciado dispensou uma sacola. Assim que conseguiram efetuar a abordagem do indiciado e do adolescente procederam a busca pessoal, sendo que com o indiciado nada de ilícito foi encontrado e com o adolescente havia a quantia de R\$ 14,00. Ao retornarem para ver o que o indiciado havia dispensado, foi constatado que se tratava de uma sacola que continha em seu interior 30 eppendorf's com cocaína. Em conversa com o indiciado e com o adolescente eles não quiseram se manifestar. No mesmo trilhar o depoimento do policial militar Igor Pedrassoli. Da prova oral colhida constata-se que na data e local dos fatos o réu praticava o tráfico de drogas não havendo dúvidas acerca da subsunção fática ao tipo penal imputado na exordial. Demais disso, não cabe falar em desclassificação para consumo pessoal (art. 28, da Lei de Drogas) como pretende o acusado ao afirmar em seu interrogatório que a droga se destinava ao uso próprio. Anoto, em acréscimo, que não há se confundir o tráfico com o propósito do uso pessoal. O art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/06 traz os critérios legais a serem sopesados nessa classificação. Cotejando-os, anoto apontarem o destino de tráfico das porções apreendidas com o denunciado os seguintes elementos: a quantidade de drogas apreendida; sua natureza e forma de acondicionamento, já que estava dividida em porções individuais prontas para comercialização; as denúncias anônimas recebidas; as circunstâncias do flagrante; entre outros. No caso presente, portanto, a tese de uso próprio é infundada, eis que nítido o propósito de traficância. Os elementos já destacados indicam, com firmeza, não se tratar de mero usuário de drogas. Conforme explicado por Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, "em geral, a quantidade de droga, notadamente em vista de sua natureza, poderá ser indicativa de mercancia. De outro lado, a forma de acondicionamento da droga (por exemplo, se embaladas para venda), o local (se próximo a pontos conhecidos como distribuição da droga, por exemplo) e horário da apreensão, assim como as demais circunstâncias em que se desenvolveu a ação (o porte de valores significativos de dinheiro, recebidos dos usuários) devem ser alguns dos critérios

norteadores do magistrado" (Lei de Drogas, 3ª ed., Método, 2013, nº 3.4.1.1, pág. 56, grifei). Cito, por oportuno, entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "TRÁFICO. Destinação a terceiros. Indícios tais como quantidade e variedade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento em porções, próprias para a venda a varejo; o dinheiro; o fato de ter sido surpreendido em atitude típica de traficância em local conhecido pelo comércio de drogas." (Apelação nº 0014475-90.2012.8.26.0405, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, j. 04/07/2013). Ademais, deve-se observar que a alegação de uso não tem o condão de, por si só, evitar condenação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas. Até porque não é incomum a figura do usuário-trafficante, até para sustentar o próprio vício. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no julgamento da Revisão Criminal nº 0142902-25.2013.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Pedro Menin, j. 06 de fevereiro de 2014, entendeu que "como é sabido, mesmo sendo o agente usuário de drogas, isto não impede que seja, também, traficante, sendo comum usuários comercializarem drogas justamente para obter dinheiro para sustentar o vício. Nessa esteira: "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104)". Na espécie, portanto, os elementos acima deduzidos indicam, com segurança, que a droga não se destinava ao consumo pessoal do denunciado mas sim para a entrega a consumo de terceiros. Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o infrator seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa. É o que se vê do seguinte excerto extraído do julgamento da Apelação nº 0000166-49.2013.8.26.0334, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. PENTEADO NAVARRO, j. 26 de junho de 2014, "a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 33, nº 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614). Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (=circunstâncias ligadas ao fato probando) envolvendo o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (=praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano (CPC, art. 335). Aliás, a questão em exame comporta a aplicação analógica das normas aludidas (art. 48 da Lei c/c art. 3º do CPP). Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (...)" . Por oportuno, "O tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar para a incriminação do fornecimento (Precedentes). II - O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio. (Precedentes)"

(STJ Resp nº 1133943/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 17/05/2010). Demais disso, as palavras dos agentes de segurança são harmônicas e encontram fundamento no conjunto probatório. Assim, se não há nada nos autos capaz de desabonar as seguras e coerentes declarações dos agentes de segurança não se provando que fossem desafetos do agente delitivo ou contra ele tivessem hostil prevenção, ou ainda quisessem perversamente prejudicá-lo é de ser decretada a condenação nelas baseada, até menos em homenagem ao trabalho daqueles que colocam suas vidas em risco pela segurança da coletividade. Como ensina a prelibada doutrina de Guilherme de Souza Nucci defende a validade dos depoimentos

de policiais afirmando que: (...) preceitua o art. 202 do CPP que toda pessoa pode ser testemunha, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª edição, São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais, 2007. página 323). Ademais, as palavras das testemunhas, agentes de segurança, são provas fartas da ocorrência do crime, sendo unívocas e cristalinas, sendo certo que revestem-se, salvo prova em contrário, de legitimidade e veracidade quando ao conteúdo relatado, pois como preleciona a jurisprudência pátria: O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF - HC 74. 608-0/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 18. 02. 97 - DJ 11. 04. 97). E ainda: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante transportando grande quantidade de droga - Confissão da posse da droga - Depoimento do policial confirmando a apreensão dos entorpecentes com o réu - O depoimento de policial tem validade como o de qualquer outra testemunha - Relato que se mostra coeso com as demais provas colhidas - Condenação mantida - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - Comprovação de que a droga se destinaria à mercancia - Alegação de viciado não obsta o reconhecimento do tráfico - Réu que não dispunha de recurso financeiro para o armazenamento de todo o entorpecente para futuro consumo - Quantidade de droga e forma de acondicionamento demonstram a intenção da mercancia - Outras delações aos policiais já davam conta que o réu vendia drogas no local - Sentença recorrida confirmada - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJSP Recurso de Apelação de nº. 990.10.167.209-0 - Rel. Dês. Amado de Faria, julgamento em 29/09/11). O auto de exibição e apreensão colacionado aos autos espelha fielmente as palavras dos Policiais. O(a) acusado(a) foi preso em circunstâncias que não deixam dúvidas sobre a prática do tráfico: fugindo à abordagem policial; informações anônimas dando conta de que o denunciado traficava na região; versão firme e coerente dos policiais e considerável quantidade de drogas, dinheiro sem origem lícita; tudo autoriza o reconhecimento da prática do delito objeto de apuração. A negativa do(a) acusado(a) restou isolada nos autos, sem nenhum fundamento. O laudo de exame toxicológico juntado aos autos confirma que as substâncias encontradas com o(a) réu(ré) se tratam de drogas. Nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, aquele que tem em depósito e guarda ou transporta, com o intuito de venda, drogas é traficante. Com relação à quantidade, irrelevante se mostra para fins de reconhecimento do delito a droga apreendida, eis que o bem jurídico penalmente tutelado não é apenas o bem estar do usuário, mas sim a saúde pública, que fica exposta a perigo concreto e iminente com a simples possibilidade da difusão do entorpecente, independentemente da sua maior ou menor quantidade, não se podendo perder de vista também que uma pequena quantidade pode ser o saldo de uma grande. Por derradeiro, caso seja alegada, saliente ainda que eventual requerimento de causa de diminuição em virtude de semi-imputabilidade decorrente de vício em substâncias entorpecentes não deve prosperar, pois aplicado perfeitamente no caso o princípio da actio libera in causa. Com efeito, o acusado, caso alegue ter praticado o delito em razão do vício em substâncias entorpecentes, se colocou, sponte propria, ao tempo da ação em nesta situação, a qual não pode ser usada para mitigar sua responsabilidade penal. Segundo leciona Mirabete "pode ocorrer que o agente se coloque, propositadamente, em situação de inimputabilidade para cometer o crime, realizando este no estado de insciência, drogando-se, embriagando-se, ou mesmo dormindo. Nesse caso, para o juízo de culpabilidade, considera-se a situação do agente no momento em que se colocou em estado de inconsciência, e não no momento da ocorrência do fato. Aplica-se, então, o princípio das chamadas actiones liberae in causa sive ad libertatem relatae, respondendo o agente pelo resultado. Esse princípio foi estendido às situações criadas culposamente pelo agente" (Código Penal Interpretado, 7ª ed., Ed. Atlas, 2011). Não há nos autos, elementos concretos de que a drogadição tenha lhe causado doença mental, apta a retirar-lhe ou

diminuir-lhe a imputabilidade. Ademais, o art. 45 da Lei nº 11.343/2006 é certo ao prescrever que o reconhecimento da inimputabilidade por conta de dependência de drogas somente ocorrerá quando esta decorrer de caso fortuito ou força maior. Diz o indigitado preceito legal: Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (nosso grifo). Vale trazer à baila os exemplos de Guilherme de Souza Nucci acerca das condições que ensejam o afastamento da culpabilidade pela drogadição, nos moldes do art. 45 da Lei de Drogas: "caso fortuito seria a ingestão de droga, proveniente do engano, do logro, do erro (ex.: o sujeito toma uma determinada bebida, que contém certo tipo de droga não aparente, enganado por terceiro, ficando completamente incapacitado para entender o que faz). Força maior seria a ingestão da substância entorpecente por atuação física superior, externa à vontade do agente (ex.: injeta-se cocaína em alguém, que se encontra amarrado ou seguro por outras pessoas mais fortes, fazendo com que perca a capacidade de atendimento)" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª ed., 2011, RT.). No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 46 DA LEI Nº 11.343 /06. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DEFENSOR DATIVO. - Se há provas de que o réu cometeu o crime, a condenação é medida que se impõe. - Deve ser decotada a majorante do emprego de arma de fogo, se os elementos dos autos demonstram que a arma, no momento da prática do crime, não tinha aptidão para efetuar disparos. - Inexistindo comprovação de que o réu estava sob o efeito de drogas, no momento da prática criminosa, bem como de que a ingestão dos entorpecentes se deu em razão de caso fortuito ou força maior, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343 /06. - Fixa-se o regime prisional aberto aos condenados, não reincidentes, a pena inferior a 4 (quatro) anos. - Cabe isentar do pagamento das custas processuais o réu, desde que assistido por Defensor Dativo, com base no art. 10 da Lei estadual nº 14.939/03. TJ-MG - Apelação Criminal APR 10058120007420001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 18/03/2013. Não há nos autos qualquer menção aos requisitos legais acima invocados (caso fortuito ou força maior), razão pela qual tal tese, caso invocada, deverá ser afastada. Há provas suficientes para a condenação razão pela qual a denúncia deve ser julgada procedente. Passo a analisar a necessária fixação da pena e do regime penitenciário a ser adotada por este inclito juízo. Na primeira fase de aplicação da sanção, ao magistrado é concedida ampla discricionariedade, regrada diga-se, dentro dos limites mínimo e máximo para a fixação da pena base. Assim, considerando todos os elementos previstos no artigo 59 do Código Penal que se amoldem ao caso concreto, deve o juiz, analisando as circunstâncias judiciais, fixar a pena base mais condizente com a realidade fática dos autos. Nessa esteira, entende a prelibada lição de Mirabete que: "Trata o art. 59, caput, e seus incisos I e II, da fixação da pena-base como primeira etapa da aplicação da pena privativa de liberdade, ou seja, a da pena-base entre os limites da sanção fixados abstratamente na lei penal, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sendo a culpabilidade do agente a base fundamental para a individualização da sanção a ser aplicada ao caso concreto, a reprovabilidade de sua conduta deve ser aferida para a fixação da pena-base. Refere-se, portanto, o caput do art. 59, às circunstâncias, chamadas de judiciais pela doutrina, que são os fatores dessa fixação". (MIRABETE, JÚLIO FABBRINI, in Código Penal Interpretado, 5ª edição, 2005, Editora Atlas, pág. 440). Neste contexto, podemos dizer que em relação à culpabilidade, nota-se que o(s) acusados(as) agiu(ram) com excesso de reprovabilidade, disseminando na sociedade o terrível vício que destrói vidas e segrega famílias, no tocante aos antecedentes, não são

são prejudiciais, possui(em) conduta social e personalidade voltadas para a prática de crimes, tirando da prática delitiva o seu viver; as consequências do crime somente não foram piores em razão da rápida e célere atuação dos policiais; circunstâncias judiciais que autorizam a pena base acima do mínimo legal. Na

segunda sem modificações. Na terceira fase, cabível a aplicação de causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Federal n.º 11343/06, pois o réu preenche seus requisitos, já que se trata de réu primário, sem maus antecedentes e que inexistem indícios de que se dedique a atividade criminosa ou que integre organização criminosa. Como preleciona a jurisprudência: "A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra in dubio pro reo (STF HC 103.225/RN 2ª T. Rel Ministro Joaquim Barbosa J. 11-10-11). O regime penitenciário para inicial cumprimento de pena deve ser o FECHADO, em face da reincidência do agente, atendendo-se assim aos preceitos do art. 33, sendo certo que resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em decorrência da vedação do artigo 44 do mesmo Codex diante da reincidência verificada. Impossível outrossim a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista a incompatibilidade de tal instituto com as circunstâncias do delito. Certamente a substituição não foi criada pelo legislador para beneficiar traficante de drogas, crime grave que destrói as famílias e a sociedade, atingindo de forma relevante o bem jurídico saúde pública. Levando em linha de conta que o delito de tráfico de drogas é considerado assemelhado a crime hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei Federal n.º 8072/90). Com efeito, malgrado o óbice a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o crime de tráfico de drogas tenha sido afastado pela Resolução nº05/2012 do Senado Federal, cumpre ressaltar que, conforme já exaustivamente demonstrado, o acusado foi surpreendido com grande quantidade e diversidade de drogas. Então, no caso presente, a substituição é totalmente inviável, pois insuficiente para a reeducação e reinserção social do agente. Cada crime tem as suas características próprias, do mesmo modo, cada criminoso carrega consigo condições pessoais que lhe são intrínsecas. Neste sentido, a necessidade de individualizar as penas, o que significa, genericamente, adequar a reprimenda penal ao crime efetivamente praticado, bem como ao seu autor. Efetivamente, há que se ponderar que os dispositivos constitucionais devem ser interpretados de maneira a serem conjugados (ponderação de princípios), coexistindo harmonicamente uns com os outros e, portanto, malgrado a individualização da pena ser princípio constitucional (art. 5º, XLVI, CF), o combate aos crimes hediondos e aos crimes a eles equiparados também o é, porquanto elencado no rol dos direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição Federal (art. 5º, XLIII). Por esse raciocínio, penas alternativas não devem ser aplicadas a casos como os dos autos, em vista da hediondez por equiparação do crime, que recomenda maior rigor na reprimenda. Cabe citar parte da fundamentação lançada no v. acórdão proferido nos autos de Apelação nº 0079886-20.2008.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho: "No que diz respeito a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não seria possível no presente diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida suficiente e adequada. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. O que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). Os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição. Dessa forma, ante a não observância dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena é

inadmissível." Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acompanhando de perto tal caminho de vedação da substituição da pena nos casos como o epigrafado: "Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011). Pelos mesmos motivos, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer a fixação de regime penitenciário fechado para inicial cumprimento da pena. O delito de tráfico de drogas é de extrema gravidade, causando perturbações de ordem social, econômicas e referentes à saúde, cenário que impõe maior rigor no tratamento penal, de modo que se o condenado por tráfico não for severamente punido sentir-se-á verdadeiramente impune e, assim, encontrará os mesmos estímulos para manter a prática de tais crimes. Por derradeiro, INVIÁVEL a concessão do direito de recorrer em liberdade ao(s) acusado(s) seja pela primariedade, seja pelos bons antecedentes, pois tratando-se de delito de tráfico de drogas seria uma contradição dar liberdade para apelado que em toda a persecução penal ficou recolhido, a teor do que dispõe o artigo 44 da Lei Federal nº 11.343 de 2006, cumulado com artigo 5º, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal. Obtemperem-se ainda que, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme consta nos autos, necessária a manutenção da prisão para evitar a continuidade do tráfico pelo acusado. Aliás, este o entendimento da abalizada doutrina de Renato Marcão, comentando o artigo em que se baseia o apelante, onde se lê que "subsistindo os requisitos da prisão preventiva, não tem direito à interposição de recurso em liberdade o réu condenado que fora mantido preso durante o processo, como é intuitivo" (Tóxicos, Lei 11.343/2006. 9ª ed. São Paulo. Saraiva: 2014, p. 328) No mesmo trilhar o entendimento da jurisprudência pátria: "Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (STF HC 115.462/RR 2ª T. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 09/04/2013, DJE 075 de 23/04/2013) No mesmo trilhar: "Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade" (STF HC 107.796/MS 1ª T. Rel. Ministro Luiz Fux j 13/03/2012, DJE 077 de 20/04/2012). Requeremos ainda a perda dos bens e dinheiros apreendidos em favor da UNIÃO, caso algum valor tenha sido apreendido, tudo nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b" do CPB e artigo 63, §1º da Lei 11.343/06. Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu representante que esta subscreve, requer a PROCEDÊNCIA da presente ação penal para CONDENÇÃO do(s) réu(s) como incurso(s) nos artigos fixados na denúncia." Dada a palavra à Defesa, as alegações finais foram colhidas pelo sistema de gravação audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: "Vistos. JHONATAN GABRIEL DE SOUZA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.346/06. Narra a denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 15h10min, na Rua Pátio da Fepasa, nº 17, Vila São Sebastião, nesta cidade e comarca de Taquaritinga/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Ryan Henrique Bussadori, trazia consigo, para fins de tráfico, 30 unidades de cocaína, com peso líquido de 9,62g, conforme laudo toxicológico de fls. 81/83, em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 93/95). A denúncia foi recebida (fl. 96). O acusado foi citado (fls. 106) e apresentou defesa preliminar (fls. 116/119). Laudos periciais às fls. 81/83. Durante a instrução foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes. O acusado não foi interrogado, pois deixou de comparecer em juízo, injustificadamente, sendo decretada sua revelia. Em alegações finais, o representante do Ministério Público se manifestou pela parcial procedência do pedido inicial, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06. A

defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, alegando fragilidade do conteúdo probatório. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 e a fixação de regime prisional diverso do fechado. É o relatório. Fundamento e Decido. A pretensão punitiva é parcialmente procedente. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 23/25), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelas fotografias de fls. 28/29, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 30/031) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 81/83), que atestou que o resultado do exame pericial foi positivo para "cocaína". A autoria é certa e repousa sobre o acusado, conforme revelou a prova oral colhida em audiência. O réu Jhonatan, na fase inicial da persecução penal, negou a imputação delitiva. Disse que estava passando pelos predinhos quando foi abordado pelos policiais. Relatou ter se assustado e corrido. Negou ter jogado uma sacola durante a fuga e disse que observou que uma pessoa que conhece somente de vista foi quem arremessou a sacola, porque esta teria corrido quando a polícia chegou. O acusado não foi interrogado em juízo, porquanto revel. Contudo, a negativa extrajudicial apresentada pelo acusado revela-se frágil e inconsistente, sobretudo porque o remanescente da prova nos autos é seguro em demonstrar sua responsabilidade pela ação criminosa que lhe é imputada. A testemunha Igor Rafael Pedrassolli, policial militar, declarou que a polícia recebe frequentes notícias dando conta da prática de tráfico de drogas nos "Predinhos" da Vila São Sebastião. Disse que, na data dos fatos, ao passar no estacionamento dos "Predinhos", local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistou o acusado na companhia de um adolescente. Relatou que ambos avistaram a viatura e se evadiram no sentido da linha férrea. Narrou que foi efetuado o acompanhamento dos dois e que, durante a fuga, o acusado dispensou uma sacola. Relatou que na busca pessoal encontrou com o adolescente a quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais) e nada de ilícito em poder do acusado. Constatou-se que na sacola dispensada pelo acusado, havia 30 cápsulas com cocaína. Disse que ambos negaram a propriedade sobre os entorpecentes e que são conhecidos nos meios policiais por promoverem o tráfico de drogas na cidade. No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Armando Fagner Araujo. Com efeito, os testemunhos dos policiais apontam a autoria do crime, de forma que o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento para terceiros, inclusive, agindo em concurso com adolescente. Os depoimentos também foram coesos no sentido de que o acusado e seu comparsa adolescentes já era conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, bem como que o local dos fatos se trata de conhecido ponto de venda de drogas. Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, no tocante aos depoimentos de milicianos, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador. O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Nesse sentido: "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC - 2.ª T., rel. Min. Maurício Correa, DJU 13/12/1996); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente

policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC n.º 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846); e “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP – ApCrim. n.º 186.858-3 – 1.ª Câ. Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, j. 18/12/1995). Sem dúvida, o conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o acusado, notadamente a quantidade do entorpecente apreendido (9,62 gramas de cocaína), incompatível com o consumo pessoal, demonstram que a droga era destinada ao comércio ilícito. Além disso, a droga estava fracionada e acondicionada em embalagem em que é tipicamente vendida. Por outro lado, a Defesa não apresentou qualquer prova apta a afastar os relatos policiais e a apreensão perpetrada, de forma que a imputação se encontra satisfatoriamente demonstrada. Considerando os elementos de prova carreados aos autos, resta aduzir que para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante a venda de tóxicos a terceiros, pois trata-se de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada. Nesse sentido: “O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4.ª Câ., rel. Des. Hélio de Freitas, j. 12.06.2001). Todos os indícios convergem para o tráfico de entorpecentes, sendo, pois, impossível de ser reconhecida a tese apresentada pela defesa. As provas coligidas são seguras e eficazes para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor. Com estes fundamentos, passo a individualizar a pena. Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/6, em razão da natureza das drogas apreendidas. O réu trazia consigo, para fins de tráfico, cocaína, substância que apresenta altíssima lesividade à estrutura orgânica da pessoa e que detém elevado grau de dependência, tornando mínimas as chances de recuperação do viciado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Destaco que o uso de tal droga está intimamente ligado à prática de crimes, uma vez que causa potente dependência psíquica, o que frequentemente leva o usuário que não tem capacidade monetária para custear o vício à prática de delitos, para que possa obter a droga. Assim, fixo a pena base majorada em 1/6. Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, em razão da menoridade relativa do acusado, reduzo a pena ao mínimo legal, conforme art. 65, I do Código Penal, destacando-se que a reprimenda não pode ser fixada abaixo desse patamar nesta fase da dosimetria, a teor do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo, 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pois a prática do crime atingiu adolescente, razão pela qual aumento a pena em 1/6. Por outro lado, é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, posto que o acusado é primário e com bons antecedentes, não havendo indícios de que se dedique a atividades criminosas (além daquela que embasa a presente condenação), nem integrem organização criminosa. Desse modo, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em definitivo em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conquanto a pena tenha sido fixada aquém do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, necessários para a imposição do regime semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal), consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína),

bem como sua quantidade, são fatores que podem justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o aberto como o mais adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Nesse sentido os seguintes julgados: HC nº 189.960/SC, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 16.08.2012, HC nº 199.619/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC nº 225.568/ES, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 01/08/2013, e, por último, HC 283296/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

DJe 28.05.2014. Isso posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JHONATAN GABRIEL DE SOUZA DE PAULA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Atendidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, além de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser pago em favor de entidade assistencial a ser fixada em sede de execução criminal. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao réu. Anote-se. Incinere-se a droga apreendida, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos. Decreto o perdimento dos valores apreendidos, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Oportunamente, após o trânsito em julgado; comunique-se à Justiça Eleitoral e o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); e, arquivem-se os autos, com as movimentações de praxe (SAJ)." Sentença publicada em audiência, sendo apresentada às partes pela mesma plataforma digital e lida pelo magistrado ao acusado. Na sequência, o defensor interpôs recurso de apelação, sendo que o Ministério Público renunciou ao direito de recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Homologo a renúncia recursal ministerial. Recebo o recurso interposto, saindo o defensor intimado do prazo para apresentação das razões recursais. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Saem os presentes intimados." Anoto que, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, procedi a importação do arquivo de gravação desta audiência para o Sistema Informatizado SAJ. Ao final, o MM. Juiz agradeceu a todos os envolvidos na participação da presente teleaudiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Valeria Storino, digitei e atuei conjuntamente para realização do ato e certifico e dou fé da veracidade deste termo, cientes e intimadas as partes. Em cumprimento das NSCGJ, art. 1269, § 1º, o presente termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e cientificados os participantes.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA